

刑法
No316

H28-2

(配点：4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、甲に横領罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、自己が所有する不動産を乙に売却したが、乙への所有権移転登記が完了する前に、同不動産を丙に売却し、丙への所有権移転登記を完了した。
- イ. 甲は、所有権留保の約定付き割賦売買契約に基づき24回の月賦払いで、自動車販売会社から自動車を購入し、同自動車の引渡しを受けたが、3回分を支払った時点で、自己の借金の担保として、同自動車を金融業者に提供した。
- ウ. 甲は、乙から盗品を売却するよう依頼され、同盗品を丙に売却したが、その売却代金を着服した。
- エ. 甲は、自己が所有する不動産を乙に売却したが、乙への所有権移転登記が完了する前に、丙との間で金銭消費貸借契約を締結した事実及びその担保として同不動産に係る抵当権設定契約を締結した事実がないにもかかわらず、同不動産について、丙を権利者とする不実の抵当権設定仮登記を完了した。
- オ. 甲は、自己が所有する不動産について、乙を権利者とする抵当権を設定したが、その抵当権設定登記が完了する前に、同不動産について、丙を権利者とする抵当権を設定し、その抵当権設定登記を完了した。

No316	横領罪の成否					正答率	
H28-2	正解	ア 1	イ 1	ウ 1	エ 1	オ 2	38%

ア 成立する

最判昭30.12.26。判例は、山林の二重売買の事案において、「不動産の所有権が売買によって買主に移転した場合、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主はその不動産を占有するものと解すべく、従っていわゆる二重売買においては横領罪の成立が認められる」としている。本記述では、甲所有不動産の乙への売却により、その所有権は乙に移転するが、その所有名義が甲に残存しているので、法律上の占有は甲に認められる。すなわち、当該不動産は、甲からみて、「自己の占有する他人の物」に当たる。また、横領とは不法領得の意思の発現行為をいい、横領罪は不法領得の意思の発現と認められる外部的行為が行われた時点で既遂に達する。売買も横領行為に該当するが、対象物が不動産であれば登記の完了が必要となる（最判昭30.12.26）によって、不動産を丙に売却し、丙に所有権移転登記を完了する行為は「横領した」に当たる。したがって、甲には横領罪（252条1項）が成立する。

イ 成立する

最決昭55.7.15。本記述では、所有権留保の約定付売買契約において、買主が売買の目的物を不正に処分した場合、横領罪が成立するかが問題となる。判例は、被告人が、自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡しを受けた3台の貨物自動車を、会社に無断で、金融業者に対し、自己の借入金の担保として提供したという事案において、「被告人の本件各所為が、横領罪に該当するとした原判断は相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、買主が代金の支払を完了しておらず、売主である自動車販売会社に自動車の所有権が留保されているので、同自動車は、「他人の物」に当たるということを挙げている。したがって、甲には横領罪（252条1項）が成立する。

ウ 成立する

最判昭36.10.10。本記述では、盗品の処分の委託を受けた者が、盗品の売却代金を着服した場合、横領罪が成立するかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「金具は、窃盗犯人たる第一審相被告人A〔注：本記述の乙〕において、牙保者〔注：有償処分のあっせん者〕たる被告人〔注：本記述の甲〕に対しその返還を請求し得ないとしても、被告人が自己以外の者のためにこれを占有して居るのであるから、その占有中これを着服した以上、横領の罪責を免れ得ない」としている。その理由として、判例は、「刑法252条1項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以て足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない」ということを挙げている。したがって、甲には横領罪（252条1項）が成立する。

エ 成立する

最決平21.3.26（重判平21刑6事件）。判例は、他人所有の建物を同人のために預かり保管していた者が、金銭的利益を得ようとして、同建物の電磁的記録である登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したという事案において、「不実とはいえ、本件仮登記を了したことは、不法領得の意思を実現する行為として十分であり、横領罪の成立を認めた原判断は正当である」としている。その理由として、判例は、「仮登記を了した場合、それに基づいて本登記を経由することによって仮登記の後に登記された権利の変動に対し、当該仮登記に係る権利を優先して主張することができるようになり、これを前提として、不動産取引の実務において、仮登記があった場合にはその権利が確保

されているものとして扱われるのが通常である」ということを挙げている。したがって、甲には横領罪（252条1項）が成立する。

オ 成立しない

最判昭31.12.7（百選Ⅱ70事件）。判例は、被告人甲が、乙に対し自己の不動産につき根抵当権を設定した後、未だその登記のないことを利用し、更に丙に対して根抵当権を設定してその登記を了したという事案において、被告人の所為は、乙に対する背任罪を構成するとしている。その理由として、判例は、「抵当権設定者はその登記に関し、これを完了するまでは、抵当権者に協力する任務を有することはいうまでもないところであり、右任務は主として他人である抵当権者のために負うものといわなければならないこと、抵当権の順位は当該抵当物件の価額から、どの抵当権が優先して弁済を受けるかの財産上の利害に関する問題であるから、本件被告人の所為たる乙の一番抵当権を、後順位の二番抵当権たらしめたことは、既に刑法247条の損害に該当するものといわなければならない」ということを挙げている。また、横領罪の客体は「自己の占有する他人の物」であるところ、本件の客体たる不動産は、甲が所有するものであり、横領罪における「他人の物」（252条1項）に当たらない。したがって、甲には横領罪（252条1項）は成立しない。